

I nemici della conciliazione

Avv. Carlo Alberto Calcagno

Se Cristo non fosse stato crocefisso sotto Tiberio è probabile che avrebbe subito identica sorte sotto Caligola.

L'Evangelista Luca ci racconta che Gesù pronunciò questo parole: *"Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, lungo la strada cerca di trovare un accordo con lui, per evitare che ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegni all'esattore dei debiti e costui ti getti in prigione. Io ti dico non uscirai di là finché non avrai pagato l'ultimo spicciolo."*¹.

Il Salvatore si limitò a descrivere e a raccomandare quel che avveniva da secoli nel mondo romano; ma ne va da sé comunque che dopo queste parole i cattolici che hanno

¹ Luca 12, 58-59.

osteggiato la conciliazione o comunque gli strumenti alternativi al giudizio si sono dovuti confrontare anche con la propria fede.

Il *Praetor*² a Roma aveva il compito di prevenire³ e dirimere⁴ le liti, ma poteva darsi che l'accordo tra i litiganti si formasse nel percorso tra il luogo dove il creditore coglieva il debitore ed il tribunale.

Sino a Giustiniano la citazione in giudizio (*vocatio in ius*) si faceva, infatti, di privata autorità: l'attore sorprende il suo avversario in luogo pubblico e gli intimava di andare in giudizio; se questi si rifiutava il creditore chiamava dei

² In origine con il termine *Praetor* si intendeva qualunque magistrato e quindi anche i consoli che conducevano l'esercito, ma avevano anche la potestà di giudicare (*Praeibat iure et exercitu*; Varrone, *De ling. Lat.* Lib. 4, c. 14 et 16). Tuttavia erano sempre fuori Roma per le campagne militari e allora nel 387 a. C. si istituì in Roma il magistrato che da quel momento in poi mantenne questo nome.

³ Cod. Iust., Novella 17 e *passim*.

⁴ Dig., Lib. 21, *De rebus creditis*.

testimoni⁵, e al loro cospetto poteva prendere il debitore con una mano⁶ ; se questi tentava di fuggire, poteva mettergli tutte e due le mani addosso e trascinarlo nel Foro⁷: nel tragitto dunque poteva capitare che i contendenti stringessero un accordo.

Tuttavia la difficoltà della citazione per atto privato e le limitazioni col tempo apposte⁸, il

⁵ Sempre che il convenuto non fosse un infame, perché in tal caso di testimoni non ce n'era bisogno. Erano infami ad esempio gli attori o i giocolieri.

⁶ *Ut invitum obtorto collo ad tribunal rapere posset.* Procedura analoga avevamo in Atene come ci ricorda C. CANTÙ, *Appendice alla Storia Universale*, vol. Unico *Delle Legislazioni*, Pomba & C., Torino, 1839, p. 115 che dice essere necessari i testimoni per attestare la regolarità della citazione; tuttavia ad Atene non si poteva costringere un cittadino a partecipare ad un giudizio, salvo per i delitti per cui era previsto l'arresto.

⁷ Ma se il convenuto era malato o vecchio, l'attore doveva mettergli a disposizione un carro trainato da giumenti.

⁸ Il pudore delle matrone esigeva un riguardo, quindi chiamate in giudizio non era lecito metter loro le mani addosso, né si poteva chiamare in giudizio le donzelle impuberi sotto l'altrui potestà soggette (L. 22, *in princ. D. de in ius vocando*). La giurisprudenza esentava poi dall'obbligo di comparire colui che dimorava in casa, cosicché l'attore non poteva citarlo nel suo proprio domicilio, ma doveva attenderlo allorché ne usciva («*Plerique putaverunt*, dice la I. 18. D. *de in ius vocando*, «*nillum de domo sua in ius*

desiderio di sottrarsi al diritto e al rigore delle formule, fecero nascere presso i Romani l'uso di tentare la conciliazione in casa propria o di un congiunto o di un giureconsulto.

Qui esponevano le proprie ragioni e finivano per lo più di intendersi e conciliare con equità⁹.

vocari licere: quia domus tutissimum cuique refugium alque receptaculum sibi : cumque qui a inde in ius vocaret vim inferro videri»); non si poteva citare un contadino al tempo della vendemmia per non distrarlo dal lavoro dei campi; particolari categorie (donne, magistrati) potevano dare delle garanzie e promettere che sarebbero comparse in giudizio, pena anche una multa: a quel punto era esclusa qualsiasi tipo di costrizione fisica. V. G. ARCERI, *Storia del diritto*, volume unico, Stabilimento Tipografico Perrotti, Napoli, 1853, p. 320-21.

⁹ V. L. SCAMUZZI, voce *Conciliatore e conciliazione giudiziaria* cit. p. 40. "E più tardi prima di disaminare la causa avanti al pretore, si tentava sempre un amichevole accordo tra le parti: *Duae experiundae viae, una summi iuris, altera inter parietes*, Coloro che usavano del primo mezzo, dice il Noodt, usavano del rigore del diritto, e gli altri si mostravano più dolci ed umani: *ita potuit actor dare. Humanitati, nec minus licuit ei aliter agere summo iure* (Tract. De pactis ed transact., cap. I, pag. 399 e 400)" P. S. MANCINI, G. PISANELLI, A SCIALOJA, *Commentario del Codice di Procedura civile per gli Stati sardi*, volume I parte II, Presso l'Amministrazione della Società Editrice, Torino, 1857, p. 109. Cfr. Orazio, Libro II epistola I.

E anche se tale tentativo domestico non andava a buon fine si poteva appunto fruire dei buoni uffici del Pretore¹⁰.

Questo era lo stato dell'arte descritta e caldeggiata da Gesù, ma torniamo a Caligola.

L'imperatore impose una pesantissima tassa sulle liti per riempire le casse dello Stato e considerò la conciliazione, che evidentemente era molto diffusa, come una frode all'erario.

Svetonio ci racconta che Caligola pretendeva il 40 per cento della somma controversa e che condannava tutti coloro che venivano accusati di essersi accordati o di aver composto la lite¹¹.

¹⁰ Dig., Lib. 13, § 3, *De usufructu ecc.*

¹¹ G. SVETONIO TRANQUILLO, *Le vite dei dodici Cesari*, trad. Fra Paolo Del Rosso, Cugini Pombe Comp. Editori, Milano, 1853, p. 214-215. Lib. IV, 40 *De Vita Caesarum, C. Caesar Caligula* ("Pro litibus atque judiciis ubicumque conceptis, quadragesima summae, de qua litigaretur: nec fine poena, si quis composuisse vel donasse negotium convinceretur") ("Voleva che tutti quelli che litigavano gli pagassero la quarantesima parte della somma in litigio; e quelli che erano accusati d'essersi accordati, e di aver composto la lite, erano da lui condannati").

Con lo stesso provvedimento l'imperatore pretese anche l'ottava

Chissà dunque che cosa sarebbe accaduto a chi avesse raccomandato un "accordo per via" addirittura... alle folle.

Comunque anche Caligola non era molto ben visto e non solo evidentemente perché voleva imporre a tutto l'impero il culto dell'imperatore: alla fine non poté che morire con trenta pugnalate¹².

Successivamente i Vescovi nell'era cristiana furono autorizzati¹³ ad intromettersi negli affari civili dei fedeli quali conciliatori¹⁴ ed arbitri.

parte del guadagno che facevano i facchini giorno per giorno e dalle meretrici quanto ciascuna guadagnava in una volta.

E fece fare anche un'aggiunta al capitolo della legge che conteneva questi precetti: con esso non erano obbligate a pagare solo le meretrici, ma anche quelle che fossero state ruffiane (A Roma erano curiosamente dette *conciliatrices*) e pure le gentildonne che fossero state trovate in adulterio: dunque potremmo dedurne che si facesse pagare dalle donne per andarci a letto.

¹² Gli agenti del fisco nel Regno d'Italia a seguito dell'istituzione del conciliatore nel 1865 non si comportarono molto diversamente dal tiranno dato che consideravano nulli in quanto simulati tutti i verbali di conciliazione sopra le lire 30, ma la storia non racconta che abbiano ricevuto particolari punizioni.

¹³ Da rescritti imperiali di Arcadio ed Onorio.

¹⁴ Vedi l'istituto dell'udienza episcopale.

Ma arrivarono il Longobardi che non erano amici né della conciliazione, né tanto meno della religione cattolica.

Quando non ricorrevano alla vendetta e decidevano di intavolare un processo, cosa che era per la verità assai rara, c'era l'Ordalia che aspettava l'accusato.

La prova della colpevolezza o dell'innocenza veniva in altre parole affidata all'acqua fredda, piuttosto che all'acqua bollente, alla croce, ai carboni ardenti etc.¹⁵

Tali prove vennero comunque in seguito sostituite dal duello giudiziario¹⁶: si reputava che la divinità

¹⁵ Oggi invece viene affidata ai giornali o ai talk show: non so dire se abbiamo fatto o meno progressi.

¹⁶ A cui potevano partecipare anche coloro che si macchiavano di delitti capitali tramite loro campioni (v. Legge VIII dell'Editto di Rotari). Anche per i Goti ed Ostrogoti il duello giudiziario era una vera e propria mania. V. TROYA, *Codice diplomatico longobardo dal 568 al 774*, Volume secondo, Stamperia Reale, Napoli 1853, p. 123.

intervenisse a manifestare il suo giudizio tramite la sorte delle armi¹⁷.

Il duello giudiziario era meno appariscente nella sua crudezza perché di solito quelli che si scannavano nell'arena erano gli *advocati*, ovvero dei mercenari che si fronteggiavano su incarico delle parti¹⁸.

La Chiesa cercò di limitare per quanto possibile sia la faida sia l'Ordalia ad esempio con il diritto di asilo e con l'istruzione di un processo basato il più possibile sui riscontri oggettivi, ma non poté fare a meno di accogliere a sua volta il giudizio di Dio istituendo la *purgatio canonica* a fronte della quale l'ecclesiastico accusato poteva discolarsi

¹⁷ Ricordiamo che questa fu l'opinione anche dei popoli omerici come ci attesta ad esempio la presenza di duello giudiziario.

¹⁸ Rotari fu così determinato nel sostenere la bontà il giudizio di Dio che Liutprando confessò di voler eliminare il duello giudiziario, ma di non averne le forze *Liutprandi, Lib. VI, leg. 65*.

dall'accusa tramite il giuramento sulla propria innocenza¹⁹.

I più alti prelati si sentivano anche autorizzati a praticare addirittura il duello giudiziario, direttamente o tramite i propri *advocati*. L'uso di questo strumento processuale era così diffuso che in alcune parti d'Italia rimase sino al 1600²⁰.

E quanto all'inimicizia dei longobardi con il cattolicesimo basti pensare che l'editto di Rotari

¹⁹ Il cui utilizzo peraltro è attestato sino al 1546 nel Reame di Napoli. V. TROYA, *Codice diplomatico longobardo dal 568 al 774*, Volume secondo, op. cit., p. 328-329.

²⁰ E. MESSINA, *Propedeutica al diritto penale delle Due Sicilie*, cit. p. 65. L'uso dell'ordalia ebbe lunga grande fortuna e divenne uno dei capisaldi del feudalesimo: la Chiesa lo proibì soltanto nel 1215 con il IV Concilio Laterano ed introdusse una rivoluzione per l'amministrazione della prova: le testimonianze scritte sostituirono il verdetto delle armi (duello giudiziario) o le prove fisiche. J. LE GOFF, *L'uomo medioevale*, Laterza, Bari, 1987, p. 33.

Ma la proibizione a nulla sortì visto che Ottone II dovette ripristinare il duello giudiziario e il papa Innocenzo III dovette concederlo ai Beneventani che lo inserirono in uno Statuto approvato con riluttanza da Gregorio IX nel 1230 ("*Ubi vero inquisitio facienda est sive per testes, sive per iudicium Dei... PUGNAM, aquam vel ferrum, vel quocumque modo, sine iudicibus non fiat*"). V. TROYA, *Codice diplomatico longobardo dal 568 al 774*, Volume secondo, op. cit., p. 324-325

s'apriva con il principio per cui chi riceveva mandato dal re²¹ di uccidere un vescovo cattolico poteva farlo impunemente.

Con la Rivoluzione francese si inaugura un nuovo capitolo della conciliazione, ma i nemici dell'istituto non arretrano di un passo.

A partire dal 1790 si è posto in Francia ed in tutta Europa il problema del controllo del territorio dal momento che era venuto meno l'antico regime.

Si pensò dunque di affiancare l'utilizzo delle armi con una nuova organizzazione giudiziaria.

L'accesso alla giustizia divenne così di fondamentale importanza: se i cittadini, infatti, non fossero riusciti a rivolgersi alla giustizia, il governo non sarebbe stato in grado di controllarli se non appunto con le armi.

Per essere accessibile la giustizia doveva anche godere dell'informalità e della tendenziale gratuità, dal momento che era indirizzata

²¹ Il quale poteva giustificarsi in virtù di un'ispirazione divina.

soprattutto ad analfabeti e poveri.

L'Assemblea costituente decise così di rispolverare un istituto che esisteva in Francia già del 1300: sulla falsa riga dei Difensori di città, già nel 1313, gli Uditori del Cancellotto giudicavano a Parigi le cause lievi, senza apparati, senza istruzione scritta e senza spese.

Tale magistratura che ricalca peraltro quella del Baiulo²² rimase in piedi in Francia sino alla fine del 1600²³.

Nella prospettiva indicata divenne nevralgico che la giustizia di pace avesse un'organizzazione capillare che venne poi portata da Napoleone anche all'esterno.

²² Federico II istituì un Baiulo per ogni città o terra demaniale, che riprese le attribuzioni dei difensori delle città ed altre incombenze; non era un giureconsulto, ma veniva assistito da giudici detti Assessori che giudicavano secondo il suo volere e quindi piegavano il diritto all'equità e ai bisogni del tempo.

²³ Cfr. G. L. J. CARRÉ – A. CHAUVÉAU, *Leggi della procedura civile di C.J.L. Carré*, cit. p. 70.

Ma poco prima, il 26 ottobre 1790, furono dettate anche le regole per la procedura di conciliazione; tuttavia erano assai farraginose, tanto che con l'art. 37 della legge 27 marzo del 1791 si impose agli avvocati di tornare alle norme della famosa *Ordonnance* di Luigi XIV del 1667 ed i successivi regolamenti (che mantenne vigore sino al 1867)²⁴.

Quindi le polemiche di questi giorni sulla carenza della legislazione appaiono in chiave storica decisamente pretestuose: si cambiano o si emendano le leggi, ma non si osteggiano ferocemente gli istituti, se non dopo averli testati. Le nuove esigenze di controllo del territorio erano così forti che in Francia nel 1791 il principio dell'obbligatorietà della conciliazione venne addirittura inserito nella Costituzione.

²⁴ E. BONNIER, *Elementi di procedura civile*, Tommaso & C., Napoli, 1833, pp. 8-9.

Dopo sedici anni di pratica, nonostante fossero contrarie alla conciliazione obbligatoria le Corti, il Consiglio di Stato ed il Tribunato, il tentativo obbligatorio preventivo, seppure legato alle sole cause non di competenza del giudice di pace, rimase in piedi nel Codice di procedura civile del 1806.

I giudici però continuavano a non credere nel tentativo di conciliazione e quindi involse la prassi di non vietare al messo giudiziario di citare le parti a giudizio prima che il giudice di pace le avesse chiamate a sé per la conciliazione.

Le Corti avevano nella Camera dei Pari (il nostro Senato) un alleato, tanto che nel 1835 venne imposta ai Deputati l'approvazione di una legge che rendeva il divieto facoltativo (legge 25 maggio 1838): corsi e ricorsi storici...

A questo punto la conciliazione era quasi morta perché per la Corte di Cassazione francese la

manca di tentativo non era rilevabile d'ufficio e non determinava nullità del giudizio.

Il Consiglio di Stato francese però mutò parere a sorpresa e nel 1855 approntò un progetto di legge che tendeva a rendere obbligatori gli avvertimenti ai cancellieri e quindi a ripristinare di fatto la conciliazione obbligatoria preventiva.

Nell'esposizione dei motivi del progetto si rinvennero i dati statistici raccolti in Francia tra il 1847 ed il 1852: si può ricavare che su quattro comparizioni vi erano state tre conciliazioni²⁵.

Anno	Comparizioni	Conciliazioni	Non conciliazioni
1847	1.003.322	733.284	272.038
1848	995.642	704.604	281.038
1849	1.112.006	808.765	393.241
1850	1.180.065	865.808	314.267
1851	1.246.026	920.749	352.277

²⁵ P. S. MANCINI, G. PISANELLI, A SCIALOJA, *Commentario del Codice di Procedura civile per gli Stati sardi*, op. cit., p. 112.

1852	1.344.296	988.900	355.396
------	-----------	---------	---------

Nonostante avesse dato buona prova di sé il tentativo obbligatorio di conciliazione fu incredibilmente abolito nel 1856²⁶.

Invece da noi si pensò nel 1865 che siccome il tentativo di conciliazione aveva fornito un buon servizio sotto un governo assoluto (Regno delle Due Sicilie e Stati Sardi), non avrebbe potuto fare a meno di crescere e svilupparsi felicemente anche nell'Italia libera²⁷.

Così come la costituzione che ancora ci regge prese a modello lo Statuto siciliano, cent'anni prima, nel 1865 appunto, il codice di rito dell'Italia Unita si ispirò alla normativa del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie* del 1819 (per la

²⁶ La procedura facoltativa invece resistette sino al 1949. Oggi invece abbiamo in Francia la *conciliation* (dal 1978; che è istituzionale, giudiziale stragiudiziale ed in alcuni casi obbligatoria), la *mediation* (affidata ad un singolo mediatore o ad organismi privati) e dal 1995 la mediazione su invito del giudice che però non lo spoglia del potere di conciliare.

²⁷ L. SCAMUZZI, *Manuale teorico-pratico dei Giudici Conciliatori e dei loro Cancellieri ed Usceri*, III ed., E. Rechiedei & C., 1893, p. 9-10.

conciliazione preventiva) e a quello degli *Stati sardi* del 1854 (per la conciliazione giudiziale).

La conciliazione era all'epoca volontaria per le parti, ma obbligatoria per il giudice.

Forte era la speranza che il legislatore riponeva nella procedura amministrata dai giudici conciliatori, anche se nei fatti essa era avversata dai municipi, dai notai, dagli agenti delle tasse e dagli uffici giudiziari in genere e pure dal governo che non aveva soverchio desiderio di nominare i conciliatori.

Insomma gli attacchi alla conciliazione erano esattamente quelli che stiamo vivendo nel 2011.

La gente che in allora era davvero povera, per lo più analfabeta ed incapace ad affrontare qualsivoglia viaggio, aveva trovato *in loco* comunque una figura di riferimento per poter gestire anche situazioni complesse come ad esempio quelle ereditarie.

Interessante è che spesso si facevano conciliazioni

anche per la correzione di errori catastali: una parte chiedeva all'altra il rimborso delle imposte pagate per errore ed il verbale con cui l'altra parte si impegnavano a pagare il dovuto, veniva appunto inviato a catasto²⁸.

Insomma i conciliatori, in un regime di conciliazione valutativo, svolgevano una funzione sociale importante.

Ma ciò non andava bene all'amministrazione finanziaria. Gli agenti delle tasse quando i verbali di conciliazione superavano le lire 30 li consideravano sempre atti simulati e nulli.

Gli uffici del catasto si rifiutavano di ricevere i verbali di conciliazione che concernevano immobili²⁹³⁰.

²⁸ Naturalmente gli agenti delle imposte non erano molto contenti e pretendevano che si adisse la commissione amministrativa competente. L. SCAMUZZI, *Manuale teorico-pratico dei Giudici Conciliatori*, p. 231.

²⁹ Per superare il problema si dovette aspettare il 1938 quando venne emanata una norma (abrogata espressamente nel 2009) per fare chiarezza sugli atti traslativi disposti con verbale di

Gli atti di compravendita, divisione, mutuo, liberazione, rinuncia all'eredità o accettazione con beneficio d'inventario, che venissero presentati ai ricevitori del registro o conservatori delle ipoteche, venivano dichiarati nulli ed inefficaci, se non c'era in piedi una vera e propria controversia³¹.

conciliazione del conciliatore e concludere quindi la “guerra” tra l'amministrazione giudiziaria e quella finanziaria: “I verbali di conciliazione redatti avanti ai giudici conciliatori, possono considerarsi, quando danno luogo a trasferimenti, come titoli validi alla esecuzione delle vulture, ma devono essere assoggettati alla formalità della registrazione ed al contemporaneo versamento dei diritti di voltura. Quando però gli immobili, oggetto del trasferimento, hanno un valore non superiore a lire 400, i verbali non sono soggetti alla registrazione a mente dell'art. 129 della tariffa allegato A, parte II, della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e quindi i diritti di voltura devono riscuotersi dai procuratori del registro su richiesta degli interessati mediante rilascio di bolletta. Il limite è quello della competenza per valore del conciliatore”.

³⁰ In quegli anni si chiedeva che gli atti che superavano le lire 30 non venissero ammessi alle formalità censuarie ed ipotecarie, che venisse abrogata la norma (art. 7 C.p.c.) che conferiva efficacia di scrittura privata riconosciuta in giudizio per gli atti che eccedevano tale soglia (oggi sarebbe l'art. 322 C.p.c.), che venisse riservata solo ai notai la facoltà di rogare atti contrattuali. L. SCAMUZZI, voce *Conciliatore e conciliazione giudiziaria*, cit. p. 158.

³¹ Circ. Procura generale di Brescia 8 aprile 1869, n. 1589 e 7 maggio 1969, n. 2121 e circ. Procura generale di Venezia 16 agosto 1873; circ. Ministero di Grazia e Giustizia 19 giugno 1879, n. 12606-

Alcuni notai addirittura restituirono il sigillo allo Stato per protesta.

Sulla spinta delle lagnanze notarili³² il Ministero della giustizia ritenne dunque che in tutti i casi in cui non fosse elevata dalle parti contestazione di sorta, ossia non vi fosse una vera e propria controversia davanti al conciliatore, l'intervento di conciliazione fosse contrario alla legge e si risolvesse in una usurpazione di funzioni del notaio o del cancelliere; i verbali di conciliazione in tal caso dovevano considerarsi nulli³³.

Anche la tassazione era comunque assolutamente nemica della pratica conciliativa.

823, div. 1a, sez. 1a.

³² Con riferimento all'art. 11 del progetto di decreto 4 marzo 2010 n. 28 abbiamo avuto un'identica lamentela che ha portato a un mutamento di disciplina con riferimento ai contratti soggetti a trascrizione.

³³ Circolare del ministro Tajani del 19 giugno 1879, n. 12606. Div. 1a, sez. 1°.

Il legislatore dell'Unità evidentemente alla ricerca del consenso stabilì inizialmente l'esenzione dal bollo e dal registro³⁴.

Ma dopo pochi mesi il bollo riprese ad imperare. Dal 1866³⁵ al contributo unificato dei nostri tempi registrammo così una vera e propria ossessione degli uffici giudiziari per la tassazione degli atti.

³⁴ Come il nostro legislatore che a fronte di una direttiva europea 52/08 che saggiamente proponeva di adottare alcuni criteri (obbligatorietà, sanzioni, incentivi) in alternativa, ha deciso invece di inserire ogni ben di Dio (esenzioni dalle tasse e diritti, credito d'imposta ecc.).

³⁵ V. articoli 5,6,8 c. 19 decreto legislativo 14 luglio 1866, n. 3122

L'art. 7 del codice di rito del 1865 stabilì dunque che i verbali di conciliazione fossero esenti sino a 30 lire³⁶ dalla tassa di registro e che fossero assoggettati all'imposta di bollo³⁷; tutti gli altri atti tra le parti scontavano invece bollo e registro.

Se l'accordo conciliativo riusciva erano dovuti i diritti di cancelleria per il processo verbale³⁸, per la scritturazione oltre le 4 facciate³⁹, per la copia del verbale⁴⁰ e la notifica⁴¹.

Non lo faccio notare per eccesso di noiosa pignoleria, ma solo per indicare che una conciliazione costava poco meno di un'intera causa (eccettuata la fase di esecuzione si assestava circa su 1 lira e 80 centesimi) e quindi ciò non facilitava gli accordi.

³⁶ Dal 1892 naturalmente sino a lire 100.

³⁷ Carta filigranata e bollata da dieci centesimi sino a lire 50 ed in tutti gli altri casi da una lira.

³⁸ Dai 50 centesimi a una lira e 50 per conciliazioni oltre le 100 lire.

³⁹ 38 centesimi.

⁴⁰ Dai 20 ai 23 centesimi

⁴¹ 30 centesimi.

Peraltro anche la sola nomina degli arbitri era costosa (1 lira e 13 centesimi) e se interveniva nell'ambito di una conciliazione le parti si ritrovavano a dover pagare somme davvero importanti.

Per superare il problema economico s'iniziarono a praticare, nei casi in cui si poteva, le conciliazioni orali che all'epoca nessuno si sognava di non adempiere: non era sentita dunque alcuna necessità di una tutela esecutiva, seppure la legge la stabilisse entro la competenza del conciliatore. Qualche anno dopo in un regime dunque di mediazione facoltativa, la relazione Zanardelli al re (1882) forniva alcuni dati statistici sulla conciliazione (quelle orali non erano naturalmente censite).

Premesso che 70,84 su 100 cause⁴² venivano in Italia risolte dai conciliatori, 32 cause su 100 venivano conciliate (82 su 100 a Napoli e 91 su 110 in Sicilia per quanto qui la conciliazione preventiva fosse praticamente inesistente)⁴³.

L'esito era dunque incoraggiante nonostante tutte le difficoltà; nel frattempo si considerò esigenza improrogabile quella di un giudice conciliatore anche nel campo del lavoro industriale⁴⁴ e nel 1895 vennero creati i collegi dei probiviri. Tale istituzione che non fu originaria del nostro paese⁴⁵ gettò comunque le fondamenta della contrattazione collettiva e svolse un'ottima attività di conciliazione anche collettiva, sino a che il

⁴² Che erano guarda caso circa un milione come quelle che sono state poste base dei ragionamenti fatti per costruire il decreto del 2010

⁴³ Cfr. L. SCAMUZZI, voce *Conciliatore e conciliazione giudiziaria*, op. cit., p. 83 e ss.

⁴⁴ Per i lavoratori agricoli provvedeva il conciliatore.

⁴⁵ Così come non lo è la *judicial mediation* americana o quella belga a cui si è ispirato il legislatore del 2010.

regime fascista li abolì nel 1928⁴⁶ e le controversie passarono al pretore e al tribunale, nell'ambito della loro competenza per valore⁴⁷.

Ma ben prima, nel 1922, il Fascismo pensò di porre fine implicitamente anche alla funzione del conciliatore: con il r.d. 20 settembre 1922, n. 1316 si stabilì che il pretore, se le parti glielo richiedevano, poteva pronunciare inappellabilmente sulla causa quando vi fosse ragione di ritenerla devoluta alla competenza del conciliatore⁴⁸.

Il conciliatore risorgerà, peraltro a grama vita, solo nel 1941. La conciliazione resterà però per tanti anni soltanto monopolio del mondo lavoristico (la legislazione settoriale in altri campi è davvero ben poca cosa).

⁴⁶ A cui rimase la definizione delle controversie pendenti sino al 31 marzo 1929. Art. 25 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 471.

⁴⁷ Art. 1 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 471.

⁴⁸ Art. 12. Ciò denota decisamente una scarsa considerazione per l'antica magistratura.

Anche la conciliazione giudiziale verrà considerata come una mera eventualità per oltre cinquanta anni.

Sino a che nel 2009 la direttiva 21 maggio 2008, n. 52 turba anche i sonni del legislatore italiano⁴⁹. Inizia dunque un percorso con il decreto legislativo 18 giugno 2009, n. 69 che delega al governo ad approntare un testo di legge in materia di conciliazione: così viene alla luce il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 sulla mediazione finalizzata alla conciliazione.

Ben prima che esca questo decreto si fanno sentire i notai e gli avvocati che fanno cambiare il progetto di legge.

Poi è la volta delle Direzioni Provinciali del Lavoro e dei Sindacati che non vogliono usurpazioni in sede lavoristica e così fanno precisare meglio ed a

⁴⁹ Quello Greco sulla scorta della direttiva ha ad esempio approntato una disciplina nel dicembre del 2010.

scanco di equivoci, l'art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Si scagliano contro la mediazione soprattutto gli avvocati: alcuni senza un particolare motivo, altri, i più illuminati, capiscono al volo che la mediazione implica un cambio di mentalità, di funzione, di metodologia di lavoro; è dal momento che oggi è già terribilmente faticoso e complicato andare in giudizio, molti vengono presi dallo sconforto, dalla repulsione e in qualche caso da un vero e proprio terrore.

Ma ciò non si può confessare e allora si grida allo scandalo perché si è prevista la mediazione obbligatoria. I vertici⁵⁰ dell'avvocatura scrivono addirittura che *"la conciliazione obbligatoria*

⁵⁰ Consiglio nazionale forense, Ordini Forensi, Unioni regionali forensi, Organismo unitario dell'Avvocatura, Associazione nazionale forense, Unione delle Camere penali.

costituisce un unicum eccezionale e stravagante nella legislazione europea"⁵¹.

Affermazione politica davvero temeraria.

Sin dai tempi antichi gli strumenti alternativi (conciliazione, arbitrato) sono stati "preferiti" al processo e quindi sono stati considerati, seppure in modo atecnico, "condizioni di procedibilità"; in campo internazionale ciò è accaduto specie in riguardo alla prevenzione dei conflitti armati.

In tempi più recenti il tentativo preventivo di conciliazione è stato sicuramente obbligatorio nel XVIII secolo in Olanda, nel Cantone di Ginevra (1713-1816), nei Paesi Bassi ed in Prussia (1745). Nello Stato sabaudo (1729-1770) si affidò la risoluzione delle controversie tra le genti rustiche a mezzi alternativi obbligatori e non è certo un caso isolato.

⁵¹ Il Consiglio Nazionale Forense in tutte le componenti predette ha ritenuto in data 18 settembre 2010 di emettere una determinazione con cui ha chiesto il rinvio dell'entrata in vigore della mediazione obbligatoria.

E questo stato di cose si protrasse anche successivamente alla Rivoluzione francese quando la tendenza, di costume o di necessità, a praticare uno strumento extraprocessuale divenne testo giuridico.

Rammento i casi della Francia (1790), della Danimarca (1795), della Repubblica Cisalpina (1797), della Repubblica Ligure (1798-1805), della Liguria come annessa alla Francia (1805-1814) della Norvegia (1800), della Spagna (1812 e 1856), dell'Austria e domini (Lombardia e Venezia) 1815, dell'Impero ottomano (con riferimento alle relazioni consolari dei sudditi austriaci) (1855), dei Codici di commercio Ungherese e Portoghese (1800-1850), del Codice di procedura civile estense del 1852.

Nell'Italia post-napoleonica i giudici minori erano in realtà degli arbitri che giudicavano senza particolari formalità e quindi le loro decisioni erano inappellabili.

Il tentativo di conciliazione preventivo⁵² diventa facoltativo per le parti (ma non per il giudice) solo nel Regno delle Due Sicilie a partire dal 1819, ma si deve tener conto che comunque all'epoca in diverse materie la faceva da padrone l'arbitrato obbligatorio che terrà sino al 1960⁵³.

Costante è la fuga dal formalismo processuale ed il rispetto del controllo privato delle forme della contesa.

La conciliazione come condizione di procedibilità è presente per quanto riguarda l'Italia nel Codice della Marina Mercantile del 1865, nella legge istitutiva dei probiviri, nella legge del 1926 istitutiva dell'ordinamento corporativo, nel codice di rito del '42 dove era addirittura condizione di

⁵² Salvo il caso degli Stati Sardi che hanno sempre rifiutato l'obbligatorietà di un tentativo preventivo, ma avevano comunque un tentativo giudiziale obbligatorio per il giudice,

⁵³ Nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni il tentativo di conciliazione si mantenne obbligatorio anche nel regno delle Due Sicilie.

proponibilità della domanda in ordine alle controversie collettive.

Venuto meno l'ordinamento corporativo il tentativo di conciliazione obbligatorio preventivo davanti alle associazioni sindacali "sostituisce" come condizione di procedibilità del successivo giudizio, l'obbligo di denuncia all'associazione sindacale previsto nel periodo fascista.

A seguito degli strali della Corte costituzionale si adotta invece, sempre in materia tentativo di conciliazione lavoristico, il regime della facoltatività, ma già nel 1973 e poi nel 1990 riprende il viatico obbligatorio in sede giudiziale ed in relazione al licenziamento; dal 1998 abbiamo ancora per tutta la materia del lavoro un doppio tentativo obbligatorio, giudiziale e stragiudiziale a cui si aggiunge l'obbligatorietà del tentativo davanti alle Commissioni di certificazione nel caso in cui si voglia impugnare un contratto certificato.

E solo a partire dal 5 novembre 2010 si è tornati ad un tentativo extragiudiziale di conciliazione facoltativa nella materia del lavoro.

Da 1995 al 2006 poi il tentativo di conciliazione giudiziale si mantiene obbligatorio anche per il processo civile ordinario.

Troviamo ancora il tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità in materia di pubblici servizi, di telecomunicazioni, di sub-fornitura, di pubblico impiego e di diritto di autore.

Emerge alla luce degli esempi tratteggiati che in passato le controversie si risolvevano o con una conciliazione perlomeno "sentita", quando non disposta dalla legge, come condizione di procedibilità, oppure in arbitrato molte volte congiunto o susseguente ad una composizione amichevole.

Si può dunque legittimamente discutere se la "trasposizione" dell'obbligatorietà in materia civile e commerciale operata con il decreto legislativo 4

marzo 2010, n. 28 sia stata o meno opportuna ai tempi nostri, ma è opportuno meditare anche sul fatto che la storia dell'istituto conciliativo, nonché del metodo alternativo in generale, ci fornisce plurimi esempi, anche di durata decisamente ragguardevole, dell'uso della condizione di procedibilità e in generale della imposizione dello strumento alternativo extragiudiziale od endoprocessuale; negarne la presenza è in primo luogo come ignorare la storia dell'istituto.

Basta poi ripassare un poco di diritto comparato per verificare che il procedimento informativo sulla conciliazione preventiva è previsto obbligatoriamente dalla legislazione francese a partire dal 2003⁵⁴ e la conciliazione è poi

⁵⁴ Con la legge di orientamento e di programmazione per la giustizia si è dato al *juge d'instance* e al *juge de proximité* anche il potere di "costringere" le parti a partecipare almeno ad un incontro informativo davanti al conciliatore. Attualmente il giudice può imporre alle parti, nel settore ben delimitato della determinazione dell'esercizio della potestà genitoriale o delle misure provvisorie in materia di divorzio, di partecipare a un incontro informativo sulla

obbligatoria in caso di divorzio e nei procedimenti davanti al *conseil des prud'hommes* ⁵⁵.

Sempre in Francia la commissione dipartimentale di conciliazione in materia di contratti di locazione abitativi conduce un tentativo di conciliazione che è obbligatorio: del pari avviene per la vendita diretta ed in tema di pubblicità in relazione alla partecipazione delle industrie⁵⁶. In caso di immatricolazione dei veicoli a motori e per i reclami davanti alla Banca centrale tedesca si

mediazione, che è gratuito per le parti e che non può costituire oggetto di alcuna sanzione particolare (articoli 255 e 373-2-10 del codice civile).

⁵⁵ Qui se non partecipa l'attore l'istanza viene caducata anche se può essere riproposta un'altra volta; se non partecipa invece il convenuto il procedimento continua come contenzioso. V. *amplius* l'illuminante *excursus* sul diritto comparato della professoressa CUOMO ULLOA (*LA CONCILIAZIONE*, op. cit. p. 125-137). Il *Conseil des Prud'hommes*, è organo giurisdizionale specializzato per decidere su controversie tra datori di lavoro e lavoratori. Il procedimento del tentativo di conciliazione è regolamentato dagli articoli del *Code du travail* (L. 511 comma 1 e R. 516 e seguenti). Cfr. http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_fra_it.htm

⁵⁶ Cfr. DG SANCO, *Study on the use of Alternative Dispute Resolution in the European Union*, cit., p. 194 e 197 ss

tiene invece un arbitrato obbligatorio⁵⁷.

La mediazione obbligatoria si ritrova in particolare prima nei singoli länder (ossia nei dipartimenti; v. ad es. in Baviera), e poi *in toto* a partire dal 2002. In Germania un dipartimento può prevedere per legge regionale⁵⁸ che non sia ammissibile intentare una causa se non dopo aver esperito un tentativo di conciliazione presso un organo di conciliazione riconosciuto.

Ciò vale per le controversie patrimoniali di valore non superiore a 750 € e per determinate controversie nell'ambito del diritto di vicinato o in materia di diffamazione. In questi casi, l'azione giudiziaria proposta senza aver prima esperito un tentativo di conciliazione viene respinta in quanto inammissibile.

⁵⁷ Cfr. DG SANCO, *Study on the use of Alternative Dispute Resolution in the European Union*, cit., p. 204 e 205.

⁵⁸ Ai sensi dell'articolo 15a della legge relativa all'introduzione del codice di procedura civile (*Gesetz betreffend die Einführung der Zivilprozessordnung, EGZPO*).

Alla metà del 2007 ben otto Länder hanno previsto l'obbligo di effettuare un tentativo di conciliazione extragiudiziale⁵⁹.

I procedimenti di conciliazioni inerenti alla formazione professionale⁶⁰ sono sempre obbligatori. E così per le imprese quelli in materia di prodotti finanziari⁶¹.

In Austria esiste ancora e dal 2002 una conciliazione preventiva obbligatoria quando si tratti di una controversia in materia locatizia e di proprietà immobiliare, anche di pubblica utilità; la mediazione è poi obbligatoria nelle liti di vicinato⁶².

⁵⁹ Baden-Württemberg, Baviera, Brandeburgo, Assia, Renania settentrionale-Vestfalia, Saar, Sassonia-Anhalt e Schleswig-Holstein.

⁶⁰ Cfr. articolo 111, comma 2, della legge sui tribunali del lavoro – *Arbeitsgerichtsgesetz, ArbGG*.

⁶¹ Davanti al *Department of consumer and investor protection at the Federal Financial* (<http://www.bafin.de/>). Cfr. DG SANCO, *Study on the use of Alternative Dispute Resolution in the European Union, Final Report, Submitted by Civic Consulting of the Consumer Policy Evaluation Consortium (CPEC)*, 16 October 2009, p. 201, in http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/adr_study.pdf

⁶² Cfr. http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_aus_it.htm

In Irlanda è necessaria la partecipazione a metodi ADR per il settore della pubblicità, delle pensioni, della vendita diretta e dei servizi finanziari⁶³.

In Inghilterra vi è attualmente una forte spinta verso la mediazione obbligatoria⁶⁴ e comunque nel Regno Unito c'è il ricorso obbligatorio degli operatori commerciali all'*Ombudsman* per i servizi finanziari⁶⁵.

In Belgio la mediazione è obbligatoria per le industrie nei seguenti settori: telecomunicazioni, assicurazioni, poste, diritti dell'infanzia, rapporti con il governo, rapporto con le istituzioni dell'Unione Europea, banche, energia, collocamento privato, pensioni, prodotti

⁶³ Cfr. DG SANCO, *Study on the use of Alternative Dispute Resolution in the European Union*, cit., p. 252.

⁶⁴ Cfr. J. ASH, *Compulsory Mediation – the European perspective*, 30 marzo 2010, in <http://www.mablaw.com>

⁶⁵ Cfr. *Adr consultation paper 18012011*, in http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca/docs/

finanziari⁶⁶.

In Danimarca la conciliazione è obbligatoria per le imprese nel settore del turismo in merito ai viaggi e all'alloggiamento⁶⁷ e nel settore dei mutui ipotecari⁶⁸.

In Estonia l'arbitrato è obbligatorio in materia di assicurazione⁶⁹ per le imprese, mentre è volontaria la conciliazione.

In Svezia la mediazione è obbligatoria per le controversie che ineriscono la locazione ad uso commerciale⁷⁰.

⁶⁶ Cfr. DG SANCO, *Study on the use of Alternative Dispute Resolution in the European Union* cit., p. 170 e ss.

⁶⁷ Davanti alla Pakkerejse-Ankenævnet (Travel Industry Complaint Board). Cfr. DG SANCO, *Study on the use of Alternative Dispute Resolution in the European Union* cit., p. 184.

⁶⁸ Davanti alla Realkreditankenævnet (Mortgage Credit Complaint Board) Cfr. DG SANCO, *Study on the use of Alternative Dispute Resolution in the European Union* cit., p. 185.

⁶⁹ Davanti alla Vaidluskomisjon (The Insurance Court of Arbitration). Cfr. DG SANCO, *Study on the use of Alternative Dispute Resolution in the European Union* cit., p. 189.

⁷⁰ Per esempio, se il locatore ha posto fine al contratto di locazione e il locatario non vuole lasciare l'ufficio senza ricevere un indennizzo, il locatario deve sottoporre la questione alla

Con decreto n. 138/2000, è stato introdotto in Romania l'art. 720 1⁷¹ a tenore del quale rapporti commerciali in contestazione, quando sono suscettibili di valutazione monetaria, devono essere preventivamente risolti attraverso la conciliazione diretta (*conciliere directa*) con l'altra parte.

Si tratta in sostanza di una specie di *discovery* obbligatoria: il richiedente s'incontra con la parte avversa che lo informa per iscritto delle domande giudiziali che svolgerà e della loro base giuridica, e di tutti i documenti che li supportano. L'incontro vero e proprio di conciliazione avviene decorsi 15 giorni da tale scambio. La conciliazione si formalizza un documento scritto che mostra i

commissione, perché questa provveda alla mediazione. Se il locatario non agisce in tal senso, perde il diritto all'indennizzo. Nell'ambito della mediazione, la commissione per le locazioni può pronunciarsi, tra l'altro, sul canone di locazione dell'ufficio, in termini di valore di mercato, e questo suo parere ha valore di presunzione in una successiva controversia in materia d'indennizzo.

⁷¹ Di modifica ed integrazione del Codice di Procedura Civile (*Codul de procedura civila*).

crediti reciproci in materia e punto di vista di ciascuna parte.

L'art. 109 del Codice di procedura civile prevede all'uopo che chi rivendica un diritto contro un'altra persona deve fare una richiesta davanti al giudice competente. Nei casi specifici però previsti dalla legge – ossia nel caso stabilito dall'art. 720 1 citato -, il rinvio al giudice competente può essere effettuato solo dopo il compimento di una procedura preliminare, alle condizioni stabilite da tale legge. La prova della procedura preliminare deve essere allegata alla citazione.

Anche in Grecia abbiamo dal 1995 un meccanismo simile a quello rumeno che nell'intenzione del legislatore ellenico avrebbe dovuto funzionare da *επίλυσης των διαφορών* (ΕΤΕΔ)⁷² extragiudiziale, ma nella prassi viene utilizzato soltanto come procedura preventiva al giudizio.

⁷² In trascrizione fonetica *epílysis ton diaforón* (risoluzione alternativa delle controversie). Sono dette anche RAC.

In altre parole per i procedimenti di diritto privato che rientrano in funzione della loro materia nella giurisdizione del tribunale collegiale di primo grado e per i quali il diritto sostanziale consente la conciliazione, si deve svolgere un tentativo obbligatorio⁷³.

Quando registra l'atto iniziale del procedimento e fissa la data dell'udienza, il cancelliere appone, sull'originale e sulle copie, un timbro leggibile recante l'indicazione che l'udienza avrà luogo soltanto previo tentativo di "soluzione extragiudiziale della controversia"⁷⁴.

La convocazione in udienza deve comprendere anche l'invito al convenuto a presentarsi presso l'ufficio dell'avvocato o del collegio di avvocati del ricorrente in un determinato giorno e ora, per cercar di giungere alla risoluzione extragiudiziale della controversia.

⁷³ Art. 214 A C.p.c. ellenico.

⁷⁴ "2. Κατά τη σύνταξη της έκθεσης κατάθεσης της αγωγής και τον ορισμό δικασίμου ο γραμματέας θέτει στο πρωτότυπο και στα αντίγραφα ευδιάκριτη σφραγίδα ότι συζήτηση δεν επιτρέπεται αν δεν προηγηθεί απόπειρα "εξώδικης* επίλυσης της διαφοράς".

Il progetto di legge sulla mediazione civile e commerciale⁷⁵ di prossima approvazione in Spagna prevede di introdurre un nuovo comma 3 all'art. 437 LEC⁷⁶ e un nuovo comma 2 all'art. 439 LEC, a norma dei quali in alcuni giudizi verbali⁷⁷ a causa del basso valore è obbligatorio tentare la mediazione parti nei sei mesi che precedono il deposito della domanda, ed il tentativo deve essere certificato nel verbale che conclude la procedura.

Si tratta del caso in cui si richieda in giudizio il pagamento di una somma inferiore a 1.000.000 di *pesetas*⁷⁸.

⁷⁵ *Anteproyecto de ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles*. In <http://www.mjusticia.es>. Cfr. anche B. M. CREMADES, *Ley de mediación y reforma de la Ley de Arbitraje*, 24 febbraio 2010 in www.diariojuridico.com.

⁷⁶ *Ley de Enjuiciamiento Civil*. Si tratta del Codice di procedura civile spagnolo.

⁷⁷ L'art. 250 del Codice di rito spagnolo prevede per tutta una serie di ipotesi che si faccia luogo a giudizio verbale.

⁷⁸ Art. 250 c. 2 LEC. Nel 2001 il limite era di 500.000 *pesetas* che corrispondono a 3.000 € ed oggi l'importo è stato portato a 6000 €

Nell'ipotesi descritta bisogna appunto dar prova di avere effettuato nei sei mesi precedenti alla domanda un tentativo di mediazione⁷⁹ perché diversamente l'azione è irricevibile⁸⁰.

Certo nella maggior parte degli esempi citati, specie in quelli dei secoli passati, non si adottava il modello facilitativo degli studiosi di Harvard, ma comunque il conciliatore era spesso l'unico contatto tra il potere ed il cittadino, ed era un contatto efficace⁸¹.

Si grida allo scandalo ancora perché non si è prevista l'assistenza obbligatoria dei legali: ma questo lo vuole solo il CNF per motivi di consenso elettorale, perché la base, come si è detto, ha ormai il terrore che venga emanata anche una

Cfr. anche B. M. Cremades, *Ley de mediación y reforma de la Ley de Arbitraje*, cit.

⁷⁹ Art. 437 novellato LEC.

⁸⁰ Art. 439 novellato LEC.

⁸¹ Cfr. http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_fra_it.htm

sola novità; imporre l'assistenza obbligatoria provocherebbe una rivoluzione del ceto forense.

Peraltro a livello storico tra conciliazione e mondo forense c'è sempre stata una grande distanza in forza dello stereotipo che considerava il legale nemico della concordia⁸².

⁸² *Et qui saepe credunt obtinere succumbunt; et si obtinent, computatis laboribus et expensis, nihil adquirunt* ("E chi si crede di lucrare, sovente vi perde; e se pur vince, a conto fatto del disturbo la spesa, nulla stringe"). Dalla lapide funeraria di Tomaso Capenago (1445).

"La miglior legge ed utile usanza che io abbia mai veduto, sta in Olanda; ove quando l'un contro l'altro due uomini vogliono litigare, sono obbligati ad andare dapprima dinanzi al tribunale de' giudici conciliatori chiamati, fattori di pace. Se le parti giungono con un avvocato ed un procuratore, si fa innanzi tutto ritirar questi ultimi, siccome dal fuoco che si vuol spegnere si tolgono le legna. I fattori di pace dicono alle parti: <<Voi siete dei grandi pazzi nel voler consumare il vostro denaro per rendervi scambievolmente infelici; noi vi accomoderemo senza costarvene nulla.>> Che se la forza del cavillare è troppo viva in questi contendenti, li rimanda ad altro giorno, affinché il tempo lenisca i sintomi della loro malattia; indi i giudici li mandano a chiamare una seconda ed una terza volta, ma se la loro follia è incurabile, si permette loro di litigare, siccome si abbandonano all'amputazione del chirurgo le membra cancrenate: allora la giustizia prende il suo impero" (VOLTAIRE, 1745).

"Ma niuno dirà che il conciliatore debba sempre tollerare la rappresentanza delle parti in mano di quei pseudo legali, conosciuti sotto diversi nomignoli (*faccendieri, azzecagarbugli, procuratori di*

L'allontanamento degli avvocati dalla mediazione ha origini lontane: con decreto 16-24 agosto 1790 la Costituente si affrettò a conciliare tutte le cause, vietando in questo stato preliminare l'intervento degli avvocati⁸³.

Nello stesso senso possiamo citare la legislazione olandese del 1680-1745, quella pontificia del 1782 e del 1832 e quella asburgica del 1815⁸⁴ che escludevano l'accompagnamento delle parti a mezzo di avvocati o di faccendieri.

Anche durante il dibattito sulla riforma del codice di procedura civile nel 1892 si voleva fortemente

campagna, cavalocchi, mozzorecchi; nel foro napoletano paglietti; in Francia voleurs de palais), che pur fanno ressa negli Uffici di Conciliazione, e che vivendo sulla bassa speculazione del litigio, non possono portarvi quella lealtà e buona fede, su cui deve riposare ogni amichevole componimento. Il meno che possa fare il conciliatore per sbarazzarsi di una genia avida ed ignorante, è di rinviare da una in altra udienza fintantoché il mandante si risolva a comparire in persona od a spedire un altro mandatario” L. SCAMUZZI, voce *Conciliatore e conciliazione giudiziaria*, opera cit. p. 191.

⁸³ M. RICCA-BARBERIS, Voce *CONCILIAZIONE*, op. cit., p. 642.

⁸⁴ Venne abrogata solo nel 1848.

escludere la possibilità che gli avvocati diventassero conciliatori⁸⁵.

Poi si decise di ammetterli a patto che non patrocinasero nel luogo ove prestavano l'ufficio di conciliazione⁸⁶.

Del resto, e a mo' certamente di battuta, già le XII tavole non avevano poi un grande concetto dei patroni visto che si prevedeva che qualora un patrono avesse frodato il cliente, si sarebbe

⁸⁵ Basta leggere la Tornata senatoria del 6 aprile 1892, p. 2927: ai senatori sembravano incompatibili con la figura del conciliatore, "sia per le loro abitudini naturalmente avverse alla conciliazione, sia per quel certo sospetto che nasce dal trovarsi quei professionisti eventualmente conciliatori o giudici davanti ai loro clienti dell'oggi e del domani".

L. SCAMUZZI, *Manuale teorico-pratico dei Giudici Conciliatori*, op. cit., p. 77 e ss.

⁸⁶ Non deve ingannare il fatto che la legge del 1892 li nomini espressamente: ciò non capitò per un ossequio, ma semplicemente perché la legge richiedeva la laurea od il diploma e molti di loro, al pari dei farmacisti o dei notai, non avevano, perlomeno al Sud, titolo di studio alcuno. Tanto che nel 1874 i legali esercenti da almeno dieci anni vennero di necessità pareggiati ai laureati (art. 60 l. 8 giugno 1874). L. SCAMUZZI, *Manuale teorico-pratico dei Giudici Conciliatori*, op. cit., p. 77 e ss.

sacrificato alla divinità⁸⁷.

Più seriamente si sostiene oggi che non può sussistere un obbligo di assistenza perché ciò si porrebbe in contrasto con il principio comunitario di efficacia⁸⁸<<4. *Le parti hanno accesso alla procedura senza essere obbligate a ricorrere a un professionista legale. Tuttavia non potrà essere impedito alle parti di farsi rappresentare o assistere da terzi in qualsiasi fase della procedura*>>.

Lo stesso relatore dello schema di decreto sulla mediazione in sede di Commissione Giustizia del resto assunse che siccome il considerando n. 13) della direttiva 52/08 colloca la mediazione nell'alveo della volontaria giurisdizione (*"nel senso che le parti gestiscono esse stesse il procedimento e possono organizzarlo come desiderano e porvi fine in qualsiasi momento"*), si rende

⁸⁷ "Patronus si clienti fraudem fecerit, sacer esto"; VIII, 21.

⁸⁸ V. le raccomandazioni della Commissione 30 marzo 1998 n. 257 8/257/CE e n. 310 4 aprile 2001 01/310/CE.

incompatibile l'obbligatorietà di una difesa tecnica.

Diciamo però, per amore di verità, che in virtù di alcune scelte operate dal legislatore nazionale, sarebbe quanto meno opportuno che si preparasse una futura mediazione con un professionista che conosca la materia⁸⁹: ma ciò non giustifica un rinvio della mediazione obbligatoria; le leggi si possono emettere e mutare, come abbiamo visto di recente, anche nell'arco di una serata quando c'è la volontà politica.

Si grida allo scandalo perché non si è previsto che la mediazione sia solo fatta da mediatori giuristi.

⁸⁹ Al riguardo va rilevato che la tipologia di controversie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, elencate secondo una scelta che sembra fatta a casaccio essendo difficile trovarvi un denominatore comune, si connota per avere caratteristiche tali da non poter prescindere dall'intervento del legale già in sede di previa contemplazione dei *sidera litis* (S. CHIARLONI, *Prime riflessioni sullo schema di decreto legislativo di attuazione della delega in materia di mediazione ex art. 60 legge 69/2009*, in <http://www.mondoadr.it>).

Premesso che la mediazione ha davvero poco a che fare con il diritto, si ritiene di aggiungere che nella storia dell'umanità, sino perlomeno all'Ottocento, nemmeno l'attività giudiziaria venne affidata a laureati in legge, il cui consiglio peraltro non fu mai vincolante.

Se affrontiamo la questione sul piano storico possiamo affermare senza tema di smentita che nella Grecia antica, tanto per riferirci ad una delle culle della civiltà e del diritto⁹⁰, i giuristi non esistevano, così come non esisteva la giurisprudenza; le contese venivano composte con l'utilizzo da parte dei contendenti che se lo potevano permettere di logografi giudiziari che erano retori e dovevano essenzialmente conquistare la fiducia e la simpatia dei giudici⁹¹; il

⁹⁰ Non dimentichiamo che i germi del processo penale hanno visto la luce nel mondo omerico ed i principii fondamentali del nostro processo civile sono nati in Attica.

⁹¹ La base giuridica della disputa passa in secondo piano non essendoci meccanismi atti a valutarla. V. C. BEARZOT, *Diritto e retorica nella polis democratica ateniese*, in *Dike Rivista storica del*

magistrato che istruiva il processo non era un giurista, ed infine la stessa giuria che emetteva il verdetto era formata da semplici cittadini⁹². Ai magistrati ateniesi si richiedevano⁹³, in definitiva, il superamento dei trenta anni e la probità della famiglia, della vita e dei costumi: il senato verificava che venerassero i patri numi⁹⁴, fossero pietosi verso i genitori, avessero fatto il servizio militare, non avessero debiti con l'erario, avessero reso il conto di un'altra eventuale magistratura,

diritto greco ellenistico, 9, 2006, p. 132.

Solo eccezionalmente poteva esserci una seconda arringa tenuta da una sorta di avvocato detto *sinègore*, che di solito era un politico in vista di Atene; questi non era cioè un avvocato di mestiere e non veniva retribuito. V. R. FLACELIERE, *La Grecia al tempo di Pericle*, Rizzoli, 1983, p. 278 e 288.

⁹² V. *amplius* E. CANTARELLA, *Diritto greco*, Cuem, Milano, 1994, cit. pp. 14-16.

⁹³ E subivano su questo un rigido esame denominato *docimasia* da parte del Bulé o Consiglio dei Cinquecento. Col che vogliamo sottointendere che anche chi vuole esercitare come terzo la nobile arte della negoziazione deve essere sottoposto ad un esame assai rigoroso, non però principalmente od addirittura esclusivamente incentrato sulle conoscenze giuridiche.

⁹⁴ Questo peraltro è un requisito che si resisterà per l'accesso alle professioni liberali sino all'ultima guerra.

non fossero falliti, non avessero patito sodomia e non avessero gettato via lo scudo in battaglia⁹⁵.

Nel mondo romano grande rilievo hanno senza dubbio i giureconsulti e la giurisprudenza⁹⁶ e la preparazione giuridica per un soggetto che assiste le parti è stata da un certo punto in poi essenziale⁹⁷, ma i giudici non erano necessariamente giureconsulti.

⁹⁵ C. CANTÙ, *Appendice alla Storia Universale*, cit. p. 94 e 95. La base della formazione oplitica comportava che se si abbandonava lo scudo si lasciava senza difesa anche "il vicino di sinistra"; il dovere e l'onore del cittadino-combattente era dunque quello di mantenere il proprio posto nella schiera assicurandone la integrità e la resistenza contro l'impeto nemico. V. F. CANTARELLA op. cit., p. 364-365.

⁹⁶ Perlomeno dal sorgere della letteratura giuridica ovvero nel periodo che va dalla tarda repubblica di Publio Muzio Scevola ad Ulpiano con cui il giureconsulto è ormai un pubblico funzionario e la giurisprudenza è ormai cristallizzata nella *constitutiones* imperiali. Si noti però che il ceto professionale dei giuristi nasce dalla sovversione della tradizione. Cicerone (*Delle leggi*, 2, 29,47) ci racconta che Quinto Mucio, figlio di Publio, afferma di aver udito il padre che non può essere buon pontefice colui che non abbia conoscenza dello *ius civile* (ossia delle giurisprudenza e della prassi giudiziaria). Sino ad allora era la pratica pontificale che fondava lo *ius civile* e non viceversa (v. *amplius* A. SCHIAVONE, *Il giurista*, in *L'uomo romano* a cura di Andrea Giardina, Laterza, 2001, p. 92 e ss.).

⁹⁷ V. *amplius* U.E. PAOLI, *Vita romana*, Le Monnier, Firenze, 1962, p. 168 e ss.)

Non lo erano i Pretori dell'età repubblicana, anche se si servivano di assessori legali; non lo erano gli Imperatori che pur avevano un *consistorium auditorium*, né i Presidi o i Prefetti del pretorio che a loro volta erano coadiuvati dagli Assessori e così pure i Difensori di città⁹⁸ dell'epoca imperiale, e per venire a tempi successivi, gli Sculdasci dei Longobardi, il Baiulo degli Svevi o i Consoli di giustizia dell'età delle repubbliche⁹⁹, il giudice di pace inglese¹⁰⁰, il giudice di pace francese del

⁹⁸ L. SCAMUZZI, voce *Conciliatore e conciliazione giudiziaria*, p. 44.

⁹⁹ Eccezione al principio sono forse lo Scabino di età franca che potremmo definire erede del giureconsulto romano ed il Bailo, giudice e conciliatore nelle terre non feudali che doveva essere notaio. Solo nel 1770 in Piemonte si iniziò a richiedere la laurea per i giudici di nomina regia. (Cfr. Atti parlamentari subalpini, Istituto poligrafico e zecca dello Stato, 1869, p. 360) anche se, per la verità già una norma savoiarda del 1430 (*Statuta Sabaudiae*; v. in seguito Leggi e Costituzioni di Sua Maestà del 1729 art. 2 lib. II Tit. V) richiedeva ai giudici di città e delle terre non feudali di essere dottori.

¹⁰⁰ Per questa carica i professionisti del foro venivano deliberatamente esclusi. Ma con una legge del 25 maggio 1871 si limitò l'incompatibilità all'*attorney* o *solicitor* (procuratore e avvocato) che eserciti la professione nella stessa contea. L. SCAMUZZI, voce *Conciliatore e conciliazione giudiziaria*, p. 48. Il giudice di pace in un

1790¹⁰¹, il conciliatore della Repubblica Ligure del 1798, il conciliatore italiano del 1865, i conciliatori francesi introdotti nel 1978.

Ricordiamo inoltre che lo stesso UMA¹⁰² che detta i principi di garanzia della *mediation* in America non prende posizione alcuna sulla professione e formazione dei mediatori.

La Society of Professionals in Dispute Resolution che è l'associazione dei mediatori americani non richiede al mediatore alcun titolo specifico, ma alcune abilità generali¹⁰³ ed altre specifiche.

La direttiva europea sulla mediazione transfrontaliera¹⁰⁴ richiede per preservare la qualità della mediazione codici di condotta per i

primo tempo era comunque assistito da due giuristi chiamati *Quorum*.

¹⁰¹ Che era parimenti affiancato da due assessori.

¹⁰² *Uniform mediation act* (17 ottobre 2001) redatto in collaborazione tra l'Associazione degli avvocati americani e Conferenza nazionale dei commissari per l'uniformazione delle legislazioni degli Stati.

¹⁰³ 1) Capacità di ascolto attivo, 2) capacità d'identificazione, analisi e separazione dei problemi.

¹⁰⁴ V. art. 4 della direttiva 21 maggio 2008, n. 52.

mediatori e che gli Stati membri incoraggino la formazione iniziale e successiva in modo da garantire efficacia, imparzialità e competenza della procedura in relazione alle parti: non si richiede però lo svolgimento di una particolare professione in capo al mediatore.

Nell'attuale Giappone¹⁰⁵, che è paese di *civil law* al pari del nostro, solo il 10% dei mediatori appartiene al ceto legale; per il restante 90% le professioni e le estrazioni sociali possono essere le più varie: dalle casalinghe ai pensionati di professioni non giuridiche¹⁰⁶.

Anche il diritto francese non prevede alcuna formazione particolare per esercitare la

¹⁰⁵ Che possiede un ordinamento giuridico di stampo germanistico.

¹⁰⁶ K. FUNKEN, *Comparative Dispute Management "Court-connected Mediation in Japan and Germany"*, (March 2001). University of Queensland School of Law Working Paper No. 867. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=293495> or doi:10.2139/ssrn.293495

professione di mediatore, ad eccezione del settore familiare¹⁰⁷.

In Germania coloro che svolgono professionalmente attività di ADR non costituiscono una figura professionale uniforme. I conciliatori e i mediatori vengono assunti non solo fra i giuristi ma anche e in special modo fra gli psicologi, i pedagoghi, gli esponenti del mondo degli affari e i sociologi. Pertanto coloro che svolgono attività di ADR possono avere una formazione di base diversa.

Gli avvocati che esercitano attività di conciliazione o di mediazione sono soggetti alle norme deontologiche professionali¹⁰⁸. Possono definirsi “mediatori” soltanto se sono in grado di dimostrare, tramite un’adeguata formazione, di

¹⁰⁷ Invero, per questo settore è stato istituito un diploma di mediatore familiare con decreto 2 dicembre 2003 e ordinanza 12 febbraio 2004.

¹⁰⁸ Articolo 18 del codice deontologico degli avvocati – *Berufsordnung für Rechtsanwälte, BORA*.

padroneggiare i fondamenti della procedura di mediazione¹⁰⁹.

Nei Paesi bassi il registro dei mediatori¹¹⁰ ricomprende una trentina di professioni tra le quali chi vuole mediare può scegliere comodamente.

In Romania la pratica della professione di mediatore è compatibile con la pratica ogni altra attività o professione, fatta eccezione per le incompatibilità, come indicato nelle leggi speciali¹¹¹.

Nel 1790 si disse del resto in Assemblea Costituente francese: *“Bisogna che in ciascun cantone ogni uomo dabbene, amico della giustizia, avente la speranza dei costumi, delle abitudini e dei caratteri degli abitanti, abbia solo*

¹⁰⁹ Art. 7a BORA. Cfr. http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ger_it.htm

¹¹⁰ L’NMI Register. Cfr. <http://www.nmi-mediation.nl/>

¹¹¹ Art. 13 l. 162/06.

per questo tutte le conoscenze sufficienti per divenire giudice di pace”.

Si grida allo scandalo ancora perché al mediatore la legge concede di fare una proposta di mediazione.

La previsione di una proposta in conciliazione è da tempi risalenti espediente assai utilizzato dalla legislazione europea ed interna.

Già il Codice prussiano del 1754 stabiliva che i consiglieri del tribunale cui venisse delegata la conciliazione avanzassero proposte di ragionevole componimento, impiegando i mezzi di persuasione più adatti ad ottenere la conciliazione delle parti.

La missione dei conciliatori francesi del 1790 era quella di “spegnere sin dal principio, coll’aiuto dei loro lumi e dei loro consigli, le liti da cui trovansi le parti minacciate”.

Nel caso di separazione di dote e di letto¹¹² la legislazione austriaca nel Lombardo Veneto del

¹¹² Assimilabile alla nostra separazione consensuale.

1803-15 prevedeva che il parroco prima di rilasciare l'attestato di non riuscita conciliazione, facesse ben tre ammonizioni ai separandi che sono di certo parificabili ad una proposta.

Il prudente consiglio stava alla base della conciliazione del 1819 nel regno delle Due Sicilie: interessante da notarsi è che il conciliatore etneo s'interponeva anche qualora non vi fosse stata richiesta delle parti.

Dall'Italia unita in poi il modello di conciliazione prima del conciliatore e poi del giudice di pace, perlomeno nella fase conclusiva, resta in sostanza quello valutativo: la proposta però non vincola le parti, sebbene li possa condizionare in quanto trattasi di cause rientranti nella competenza del giudice adito.

Ma alla proposta ricorrevano anche gli arbitri conciliatori¹¹³ a partire dal codice francese del

¹¹³ Nati peraltro proprio in Francia nel 1563 come arbitri-relatori per i Tribunali di commercio.

1804, per transitare in quello etneo del 1819, e poi nella codificazione italiana del 1859¹¹⁴ ed in ultimo in quella del 1865.

L'operaio italiano che nel 1895 avesse aderito alla proposta conciliativa dei probiviri era ammesso "*di diritto al gratuito patrocinio per far valere giudiziariamente le domande sulle quali abbia riportato parere favorevole*"¹¹⁵.

In tempi più recenti, attorno agli anni '80, il concetto di proposta si afferma negli Stati Uniti con riferimento alle controversie in tema di sinistri stradali¹¹⁶.

La proposta comunque non è qui però mai vincolante e non determina ripercussioni su un futuro giudizio¹¹⁷.

¹¹⁴ Si trattava in realtà del Codice sardo.

¹¹⁵ Art. 10 legge 15 giugno 1893 n. 295.

¹¹⁶ In casi in cui cioè non c'è da determinare l'*an* della responsabilità, ma solo il *quantum*.

¹¹⁷ Gli Stati Uniti hanno per la verità, anche un modello di proposta da cui scaturiscono conseguenze in materia di spese processuali, quello dell'art. 68 delle *Federal rules*; qui tuttavia non è il

In ambito europeo troviamo un primo riferimento ad una proposta nella raccomandazione della Commissione del 30 marzo 1998 98/257/CE ove si parla di procedure che, indipendentemente dalla loro denominazione, portano ad una risoluzione della controversia tramite l'intervento attivo di un terzo che propone o impone una soluzione; si fa cenno poi ad una proposta in sede di principio di equità nella raccomandazione della Commissione del 4 aprile 2001 2001/310/CE: le parti devono avere un tempo ragionevole per esaminarla e decidere se accettarla o meno, devono essere informate del fatto che la proposta possa essere meno favorevole di quel che si otterrebbe con un

mediatore che fa proposte, ma è il convenuto che sottopone all'attore un'offerta di transazione (offerta che può peraltro essere reiterata nel corso del processo anche se non ha i medesimi effetti) l'attore che non l'accetti se la sentenza sarà meno favorevole alla proposta transattiva verrà condannato al pagamento delle spese processuali successivamente all'effettuazione della proposta (non di quelle legali).

giudizio, ed in ultimo devono poter ricorrere al consiglio di un'autorità indipendente.

Ritroviamo la proposta anche riforma societaria del 2003¹¹⁸ sia con riferimento alla conciliazione preventiva, sia alla giudiziale.

La disciplina del diritto d'autore dal 2003 prevede ancora che in caso di mancato accordo vi sia una proposta obbligatoria della speciale commissione e che le posizioni delle parti vadano al vaglio del giudice addirittura d'ufficio, per il riparto delle spese processuali¹¹⁹.

Anche in materia di telecomunicazioni il responsabile del procedimento di conciliazione che è obbligatorio può suggerire alle parti una o più soluzioni alternative per la composizione della controversia¹²⁰.

La stessa norma ha novellato pure l'art. 91

¹¹⁸ Art. 40 decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

¹¹⁹ Art. 194 *bis* c. 6 decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.

¹²⁰ Art. 9 c. 4 AGCOM n. 173/07/CONS.

C.p.c.¹²¹ nel procedimento civile ed ha quindi previsto le conseguenze del rifiuto della proposta conciliativa.

Sino al 2009 se le parti non comparivano al tentativo di conciliazione o rifiutavano la proposta conciliativa del giudice non c'erano conseguenze di una qualche rilevanza¹²².

L'art. 91 prevede invece oggi che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, fermo il principio generale della soccombenza, se *"accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma*

¹²¹ Art. 45, comma 10, della l. 18 giugno 2009, n. 69.

¹²² Le uniche conseguenze si potevano produrre dal punto di vista probatorio sul procuratore, ma solo nel caso in cui non conoscesse i fatti di causa. Lo stesso tentativo di cui al 420 C.p.c. stabiliva solo conseguenze processuali in tema di prova nel caso di mancata comparizione.

dell'articolo 92¹²³.

In ultimo ritroviamo la proposta nella disciplina del tentativo di conciliazione extragiudiziale ex art. 410 C.p.c., che oggi regge sia il privato sia il pubblico impiego¹²⁴ e nel tentativo di conciliazione giudiziale di cui al 420 C.p.c.

Nel caso di tentativo ex art. 410 C.p.c. se la proposta non viene accettata *“i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non*

¹²³ Ossia della possibilità di compensare in parte o integralmente le spese.

¹²⁴ In precedenza soltanto nel pubblico impiego ed in caso di mancato accordo il collegio formulava una proposta di bonario componimento della vertenza (art. 66 c. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). In caso di adesione alla proposta, tra l'altro, la parte pubblica non restava esposta a responsabilità amministrativa. L'adesione poteva intervenire anche durante il tentativo giudiziale davanti al Tribunale (art. 66 c. 8 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Ma se la proposta non era accettata, i termini di essa erano riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti (art. 66 c. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio”¹²⁵.

Invece qualora si tratti di tentativo giudiziale ex art. 420 C.p.c. il rifiuto della proposta transattiva del giudice, senza giustificato motivo, costituisce, unitamente alla mancata comparizione, comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio¹²⁶.

Anche il magistrato tedesco attuale esamina con le parti il nocciolo della lite, può anche fare domande e alla fine può formulare una proposta di conciliazione che sottopone all’approvazione delle parti.

La conciliazione in Germania mira proprio a far sì che le parti coinvolte nella controversia raggiungano un’intesa tramite la formulazione di una proposta di compromesso da parte del conciliatore.

¹²⁵ Art. 411 c. 2 C.p.c.

¹²⁶ Art. 420 c. 1 C.p.c.

Si tenga inoltre presente che nel settore privato si può adire il giudice solo se non si è accolta la proposta del conciliatore¹²⁷.

In Finlandia la commissione per i reclami dei consumatori e quella delle assicurazioni sono tenute ad effettuare un tentativo di conciliazione a seguito del quale può effettuare, in caso di fallimento, una proposta di conciliazione¹²⁸.

In Austria la conciliazione in materia di telecomunicazioni può comportare l'effettuazione di una proposta da parte dell'organo deputato¹²⁹.

Nei Paesi Bassi ci sono *ombudsman* che intervengono nelle controversie in primo luogo per trovare una soluzione comune. Se non ci riescono emettono allora un parere non vincolante.

Ciò accade per i reclami contro un provvedimento

¹²⁷ http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ger_it.htm

¹²⁸ V. http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_fin_lv.htm.

¹²⁹ V. http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_aus_it.htm

della pubblica amministrazione¹³⁰ od in materia commerciale¹³¹. Nonostante la non vincolatività però il fornitore accetta nella maggior parte dei casi la decisione dell'ombudsman.

Ci sono poi pareri che sono vincolanti in materia di legge sulle locazioni¹³² e con riferimento alle controversie dei consumatori in una quarantina di settori¹³³.

In Svezia la commissione che si occupa di mediazione in ambito di locazioni commerciali può

¹³⁰ Davanti *all'Ombudsman Nationale* che viene nominato dal parlamento. Si tratta di una sorta di difensore civico. Cfr. <http://www.nationaleombudsman.nl/>

¹³¹ Il più importante è l'*Ombudsman Schadeverzekering* (Ombudsman per l'assicurazione danni). PO Box 30, 2501 CA The Hague, Paesi Bassi.

¹³² Emessi dalla *Huurcommissie* (Commissione affitti). Dal 1° aprile peraltro è cambiata la legge. Il ricorso non è gratuito: se il ricorrente è una persona giuridica l'indennità è di 450 €, se è una persona fisica corrisponderà 25 €. V. <http://www.huurcommissie.nl/>

¹³³ Davanti alle trenta commissioni facenti parte dello *Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken* (SGC, Ente per la risoluzione delle controversie dei consumatori): l'intervento di queste commissioni deve essere tuttavia previsto nelle condizioni generali di contratto. Cfr. <http://www.degeschillencommissie.nl>

tentare la conciliazione nell'ambito delle materie per cui decide in luogo del tribunale ordinario

In tal caso se le parti non riescono a conciliarsi in base alla proposta dell'una o dell'altra di esse, e purché non sia evidente che mancano i presupposti per giungere alla conciliazione, la commissione presenta una propria proposta di conciliazione. Se le parti non accolgono tale proposta, la commissione si occupa direttamente della controversia¹³⁴.

Abbiamo riportato un'ampia carrellata per dimostrare che l'opzione propositiva era già ben conosciuta nel diritto interno e comparato quando il legislatore della mediazione civile e commerciale ha deciso di ricorrervi e quindi non si capisce proprio il motivo di tanta ostilità.

Si grida allo scandalo poi perché si assume che i Tribunali non abbiano concesso ai consigli dell'ordine degli avvocati i locali per la

¹³⁴ V. http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_swe_it.htm

mediazione, come previsto dalla legge. Premesso che la legge non prevede che i consigli dell'ordine siano obbligati ad istituire organi mediazione¹³⁵ si aggiunge qui che le soluzioni sono molteplici, basta ricercarle. Si pensi solo all'Argentina ove la conciliazione si può svolgere anche nello studio del singolo professionista su autorizzazione del Ministero. Ma anche nei Paesi Bassi il luogo di svolgimento non è certo un ostacolo.

L'OUA (Organismo Unitario dell'Avvocatura) ha presentato addirittura ricorso al T.A.R. Lazio per vedere annullare il regolamento sulla mediazione¹³⁶, aiutato bisogna dirlo da un

¹³⁵ Anzi per il sottoscritto il fatto di prevedere la mediazione in capo ad organismi creati dagli ordini non può che portare un danno all'istituto, specie alla luce dell'atteggiamento fortemente corporativo con cui è stata accolta (fa eccezione a tale atteggiamento attualmente il solo Collegio dei geometri che non a caso sono stati i primi mediatori della storia quando ancora si chiamavano agrimensori o addirittura *arpedonapti* (tiratori di corde).

¹³⁶ Num. Reg. Gen.: 10937/2010 Data Dep.: 07/12/2010 Sezione: 1. Oggetto del ricorso: Annullamento del d.m. n. 180 del 18 ottobre 2010 avente ad oggetto "regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli

comportamento assai strano del Governo che in un primo momento ha fatto proprie le indicazioni del Consiglio di Stato sul testo (agosto 2010) e poi inspiegabilmente, ottenuta l'approvazione su un secondo testo (settembre 2010) affidato alla stampa, ha deciso di pubblicare (ottobre 2010) un decreto interministeriale con diversi dei macroscopici vizi originari.

Quasi per dire "Io ormai ci sono costretto da motivi elettorali a portare avanti la mediazione, ma voi impugnate il regolamento così la facciamo finita...>>.

Si grida allo scandalo perché si ritiene che in cinquanta ore (tanto dura il nuovo corso da mediatore) non si possa diventare mediatore: la

organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi ai sensi dell' art. 16 del d.lgs. n. 28 del 2010. Fonte: <http://www.giustizia-amministrativa.it>. In data 9 marzo tuttavia il consesso amministrativo non ha concesso la sospensiva e la discussione è stata rinviata dopo la entrata in vigore della mediazione come condizione di procedibilità.

critica è corretta se si continua a voler vedere ad ogni costo il mediatore come un esperto di diritto, cosa che non è e non deve essere e non sarà mai¹³⁷; il mediatore è un conoscitore della comunicazione e del linguaggio del corpo ed ha come unica funzione quella di ripristinare il colloquio tra le parti; non ha e non avrà mai alcuna intenzione di prendere il posto né dei consulenti legali, né di quelli tecnici. Non è che con cinquanta ore si possa fare molto anche nel settore della comunicazione, ma del resto quando si è chiesto allo Stato di promuovere sul campo coloro che hanno fatto conciliazione dal 1993 e che hanno centinaia e centinaia di ore di pratica e di studio sulle spalle si è risposto con un secco: <<No, grazie!>>.

Ma bisognava essere sicuri di impedire questo terribile morbo della conciliazione: prima ci ha

¹³⁷ Lo stesso Ministero negli spot televisivi lo ha presentato come il salvatore della giustizia e questo messaggio è stato a dir poco impreciso.

messo del suo il decreto legislativo istitutivo della mediazione con la previsione che l'esenzione dal pagamento dell'indennità restasse a carico degli organismi, ma ciò non evidentemente non bastava a dissuadere gli organismi che continuavano a chiedere l'iscrizione al registro ministeriale.

E allora si sono previste dei valori tariffari in modo che per una mediazione di scarso valore economico i mediatori riuscissero a guadagnare solo tre euro lordi.

Ma gli innamorati della conciliazione non desistevano e allora come fermarli? L'unico sistema sicuro era ritornare a fare pressioni in Parlamento

Ma qui le cose non sono andate come desideravano i detrattori della conciliazione¹³⁸

¹³⁸ Che oggi si chiama mediazione finalizzata alla conciliazione perché si vuole sottolineare che prima di conciliare le persone partecipano appunto ad una procedura di mediazione che rispetto al

dato che tra mille traversie¹³⁹ sono riusciti almeno nel contingente a strappare solo un rinvio dell'obbligatorietà al 20 di marzo del 2012 per le controversie in materia di condominio e sinistri¹⁴⁰: per il resto¹⁴¹ la mediazione come condizione di procedibilità entra in vigore il 20 marzo 2011.

Rinvio peraltro di cui chi scrive fa molta fatica a comprendere la logica.

Le controversie condominiali sono conflitti multi parte che abbisognano di procedure particolari e

passato ha diverse caratteristiche specie con riferimento a chi la conduce ossia al mediatore.

¹³⁹ Per convertire il d.l. mille proroghe il Governo ha dovuto porre la fiducia su un maxi-emendamento sia al Senato sia alla Camera.

¹⁴⁰ Cfr. art 2 c. 16-decies legge 26 febbraio 2011 n. 10. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. (GU n. 47 del 26-2-2011 - Suppl. Ordinario n.53) In vigore dal 27/02/2011.

¹⁴¹ Diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

complesse¹⁴², ma ce ne sono altre nell'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 che hanno almeno potenzialmente queste caratteristiche e per cui il rinvio non è stato invocato: se il rinvio fosse stato richiesto dagli organismi sarebbe stato dunque ragionevolmente più corposo in quanto a materie; se il rinvio non è stato chiesto da loro – come si crede fermamente – francamente non si riesce a capire¹⁴³ che cosa abbia animato le decisioni del legislatore se non il classico compromesso italiano che accontenta e scontenta tutti.

In ordine alle controversie sui sinistri la conciliazione è da considerarsi come uno sbocco

¹⁴² Ad es. la presenza di due mediatori e di sessioni preventive.

¹⁴³ Come non si riesce a capire la logica di due senatori del PDL che hanno perseguito un percorso perlomeno curioso: hanno chiesto il rinvio della mediazione obbligatoria al 31 marzo 2012, al 30 giugno 2012 e al 30 settembre 2012 e poi il rinvio parziale (emendamenti 1.246; 1.247; 1.248; 1.249; 1.250).

naturale¹⁴⁴, specie nel caso ci sia di mezzo una preventiva perizia contrattuale¹⁴⁵: e quindi a maggior ragione non si capisce la ragione di una richiesta di un rinvio.

I nemici della conciliazione non si danno comunque per vinti.

Al Senato sono stati già presentati due disegni di legge dal PD che stravolgono il dettato della legge odierna¹⁴⁶; nessuno se ne preoccupa perché in

¹⁴⁴ Peraltro negli Stati Uniti la conciliazione valutativa nasce appunto in questa materia negli anni '80.

¹⁴⁵ Siccome la perizia contrattuale involge soluzioni tecniche, anche quando sia dedotta in contratto, resta comunque spazio per la mediazione sulle questioni e controversie giuridiche, ossia sulla misura del risarcimento e sulla validità della garanzia, che appare dunque perlomeno complementare. Ed è pure probabile un accordo, visto che le parti, in presenza di una pregressa perizia contrattuale, hanno ormai accettato una determinata soluzione tecnica. Resta inoltre sempre in facoltà delle parti che abbiano scelto la mediazione di chiedere in difetto di accordo o di accordo parziale, una perizia contrattuale, limitatamente però alle questioni tecniche, ovvero resta libera la facoltà di rivolgersi agli arbitri a cognizione piena.

¹⁴⁶ Presso la Commissione permanente Giustizia del Senato sono in corso di esame le proposte di legge AS 2329 (Benedetti Valentini) e AS 2534 (Della Monica ed altri), recanti modifiche alla disciplina in materia di mediazione civile e commerciale. La Commissione Giustizia in sede referente ha peraltro approvato in

Parlamento si dice che l'opposizione non ha i numeri, ma in Parlamento non esistono i "buoni" ed i "cattivi"; la minaccia è in realtà al momento solo rinviata dato che comunque se non fosse avvenuto l'imponderabile¹⁴⁷ la mediazione obbligatoria sarebbe stata integralmente rinviata di un anno con il beneplacito di tutto l'arco costituzionale.

data 16 febbraio la congiunzione dei provvedimenti AS 2329 e AS 2534. La proposta AS 2329 che è decisamente la più lunga ed articolata assume di farsi carico dei suggerimenti avanzati dalle associazioni rappresentative del mondo forense e dei COA territoriali ed in sintesi prevede: a) assistenza obbligatoria dell'avvocato; b) cessazione della procedura in caso di assenza ingiustificata di una delle parti; c) facoltatività della mediazione; d) proposta del mediatore solo in caso di richiesta delle parti; f) proposta eventuale formulata dalle parti; e) rilevanza della mancata partecipazione o della proposta ai sensi del solo 91 c. 1 C.p.c. Entrambe le proposte di legge escludono che il ricorso alla procedura di mediazione possa appunto costituire condizione di procedibilità dell'eventuale successivo giudizio.

¹⁴⁷ Chi scrive non sa (al di là delle inconsistenti giustificazioni che si ricavano dal verbale della seduta) che cosa determinò la Commissione Bilancio ed Affari costituzionali che aveva già approvato il rinvio integrale a tirare fuori dal cappello a cilindro nell'arco di una notte un emendamento di rinvio parziale peraltro assolutamente inusuale per la prassi parlamentare.

Gli avvocati hanno proclamato ed effettuato uno sciopero dal 16 al 22 marzo del 2011, ma non se ne comprendono le finalità.

Peggio di così la nostra giustizia non potrebbe andare ed anche il loro ruolo non sembra dare risultati esaltanti.

Non usare la mediazione – dicono i vertici europei - fa aumentare i tempi medi di un processo di 331-446 giorni nell'Unione europea, con spese legali aggiuntive che vanno da 12.471 a 13.738 euro per causa¹⁴⁸.

Secondo un recente studio commissionato dalla UE del giugno 2010 l'Italia è all'ultimo posto in Europa per i tempi di media durata di una lite con 2205 giorni e al 15° posto per i costi che ammontano in media a € 19.527¹⁴⁹.

¹⁴⁸ www.europarlamento24.eu/controversie-transfrontaliere-in-italia-si-puo-mediare/0,1254,72_ART_729,00.html

¹⁴⁹ ADR CENTER, *The Cost of Non ADR – Surveying and Showing the Actual Costs of Intra-Community Commercial Litigation*, Roma, 9 Giugno 2010.

Il che significa che i nostri tempi medi di un processo¹⁵⁰ sono quattro volte quelli di qualsiasi altro paese che del pari non voglia utilizzare la mediazione e che se ci fosse la mediazione al cittadino un processo costerebbe un terzo del valore stimato attuale.

E ciò perché, aggiunge lo scrivente, come si legge sul sito ufficiale della Corte Suprema della California¹⁵¹: *"Did you know that 95 percent of all civil cases filed in court are resolved without going to trial? Many people use processes other than trial to resolve their disputes"*¹⁵².

Di certo qualsiasi cittadino sano di mente di fronte a queste considerazioni preferirebbe provare la

¹⁵⁰ Sei anni dice il recente studio, ma secondo chi scrive l'ottimismo di questo studio regna sovrano.

¹⁵¹ A presentazione del CADRE (*Court Administrative Dispute Resolution*): programma che in California funziona dal 1999 e che all'aprile del 2005 ha avuto un tasso di risoluzione dell'83%. Cfr. <http://www.sbcadre.org/>

¹⁵² "Lo sai che il 95% delle cause che arrivano in Corte sono risolte senza andare in giudizio? Molte persone utilizzano sistemi diversi dal processo per risolvere le loro dispute"

mediazione: scioperare dunque ha aggiunto alla beffa il danno.

Ma al CNF devono in parte essersene accorti ancor prima della astensione ed hanno corretto il tiro pubblicando un manifesto in cui si legge: *“L’Avvocatura, chiamata dalla Costituzione e dalla legge speciale alla salvaguardia dei diritti anche dei soggetti più deboli, non contrasta l’idea della mediazione quale complemento della giurisdizione nella soluzione dei conflitti, ma ribadisce la propria opposizione a questa normativa, tra l’altro di dubbia costituzionalità, che, per come concepita, si risolve in un percorso ad ostacoli nell’accesso alla giurisdizione, con un aumento di oneri e costi per ottenere risposta alla domanda di giustizia”*¹⁵³.

¹⁵³

Cfr. <http://www.consiglionazionaleforense.it>

Il che per dirla col linguaggio delle favole ricorda un passaggio dalla fiaba del lupo e l'agnello¹⁵⁴ a quella della volpe e l'uva¹⁵⁵.

Tant'è il vizietto di attribuire qualifiche ed effetti a qualcosa che in Italia non si è ancora sviluppato non se lo sono proprio levati: ciò che invece è già nato, lo si ribadisce, è il dato processuale di giorni 2205 per € 19.527.

In presenza di questa allarmante realtà dovrebbe scattare nella testa del legale l'art. 36 del Codice

¹⁵⁴ "Un lupo e un agnello, spinti dalla sete, si ritrovarono a bere nello stesso ruscello. Il lupo era più a monte, mentre l'agnello beveva a una certa distanza, verso valle. La fame però spinse il lupo ad attaccar briga e allora disse: "Perché osi intorbidarmi l'acqua?"

L'agnello tremando rispose: "Come posso fare questo se l'acqua scorre da te a me?" "E' vero, ma tu sei mesi fa mi hai insultato con brutte parole". "Impossibile, sei mesi fa non ero ancora nato".

"Allora" riprese il lupo "fu certamente tuo padre a rivolgermi tutte quelle villanie". Quindi saltò addosso all'agnello e se lo mangiò".

¹⁵⁵ "Spinta dalla fame, la volpe cercava di prendere l'uva da un'alta vite, saltando con tutte le sue forze, ma non riuscì a toccarla; allora andandosene disse: "Non è ancora matura; non voglio coglierla acerba". Chi sminuisce a parole quello che non è in grado di fare, dovrà riferire a se stesso questo esempio". Questo racconto è rivolto a tutti coloro che opprimono i giusti nascondendosi dietro falsi pretesti.

deontologico che impone all'avvocato di non consigliare azioni inutilmente gravose e invece paradossalmente si ritiene gravosa la mediazione che si svolge spesso in un solo giorno.

È certo un grande ostacolo alla giustizia un'esperienza che al minimo fa perdere qualche ora di tempo (se ne perdono tante su internet a giocare a *videopoker*...) e che al contrario potrebbe cambiare addirittura la vita delle persone (altro che risolvere la controversia!).

Ma gli irriducibili detrattori non demordono.

Si vocifera di atti di citazione che non solo solleveranno in tutti i Tribunali della Repubblica l'incostituzionalità del decreto legislativo, ma che recepiranno l'intimazione a partecipare alla mediazione con termine di comparizione nel processo a quattro mesi e quindici giorni.

I brillanti avvocati non hanno però messo in conto che le cause si fanno in due e che quindi se si addviene ad un accordo, cosa molto probabile

visto che il loro assistito non è - come essi credono - una variabile secondaria, il collega della controparte si costituirà chiedendo il pagamento delle spese di un giudizio instaurato a sproposito.

E quindi il cliente che sarà uscito soddisfatto dalla mediazione si troverà ad aver pagato (o a dover pagare) il suo avvocato per la procedura di mediazione e per un processo che non si terrà mai, lo stato in virtù di un contributo unificato inutile, la controparte per le spese di un giudizio instaurato senza alcun senso dal proprio legale.

È questo di certo un modo originale per fidelizzare il proprio assistito!

Ma gli avvocati alla fine capiranno e come è successo nei grandi paesi diventeranno in qualche lustro gli assertori più convinti degli ADR: come San Paolo passeranno da nemici giurati dello strumento a protagonisti ed interpreti principali della procedura.

E per chi non vuole proprio arrendersi c'è comunque la possibilità dell'espatrio: in Grecia ad esempio si presenta uno scenario assai favorevole poiché per fare il mediatore bisogna essere avvocati accreditati dal Ministero della Giustizia¹⁵⁶,

¹⁵⁶ Ex art. 7 c. 2 l. n. 3898/10 è il Ministro della Giustizia a stabilire i termini e le condizioni per l'accreditamento dei mediatori, il codice di condotta per mediatori accreditati, le sanzioni per la violazione del predetto codice, qualsiasi questione che riguardi la mediazione.

Un dipartimento del Ministero della Giustizia è poi in particolare responsabile per l'accreditamento dei mediatori e dell'adozione di misure amministrative necessarie per l'accreditamento.

Vi è una Commissione certificatrice dei mediatori (art. 6 l. n. 3898/10) che opera sotto la supervisione del ministero della Giustizia e che si occupa anche del controllo del rispetto degli obblighi degli organismi di mediazione, della conformità dei mediatori accreditati al codice di condotta e alle raccomandazioni del Ministro della Giustizia, nonché della comminazione delle sanzioni stabilite dal Ministero (revoca temporanea o permanente dell'accreditamento).

La Commissione è composta da un presidente e quattro membri e un numero uguale di supplenti. La durata del mandato è di tre anni.

La certificazione dei mediatori avviene a seguito di esame che consente di verificare se il candidato abbia le conoscenze, le competenze e la formazione adeguata per fornire servizi di mediazione e la decisione è scritta e ben motivata.

Il Ministro della Giustizia di concerto con il Ministero delle Finanze approva il regolamento della Commissione e degli esami, l'emolumento dei membri della Commissione, la tassa di partecipazione all'esame, la determinazione del procedimento di

e anche l'ADR obbligatorio viene comunque gestito dai legali¹⁵⁷.

Non consiglio però la Finlandia perché in quel paese anche l'assistenza del legale nel processo è meramente facoltativa¹⁵⁸.

Ma all'orizzonte si addensano anche altre insidie.

I Librai che non sono nemici della conciliazione speravano in un rinvio integrale per non continuare ad essere subissati di richieste di pubblicazione¹⁵⁹ in materia di strumenti alternativi.

Tuttavia hanno trovato nel Ministero della Giustizia un insperato alleato.

controllo degli enti di formazione accreditati per i mediatori e i facilitatori.

¹⁵⁷ Art. 214 A C.p.c. che è entrato in vigore nel 2000 e che è stato modificato nel 2002: quindi per ora non ci sono grandi minacce all'orizzonte.

¹⁵⁸ http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_fin_it.htm

¹⁵⁹ Da parte di coloro che vogliono diventare formatori di mediatori.

Il Ministero ha ribadito, infatti, di recente¹⁶⁰ che *“il requisito delle pubblicazioni di almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie è stato individuato facendo specifico riferimento a queste specifiche condizioni: a) che si tratti di pubblicazioni scientifiche, giuridiche specializzate, a diffusione nazionale dotate di codice ISBN per i libri e ISSN per le pubblicazioni in serie; che si tratti di pubblicazioni scientifiche, giuridiche specializzate, ufficiali edite o prodotte da organi dello stato, regioni, province, comuni ed enti pubblici. Non possono essere considerate valide, ai fini di cui sopra, le pubblicazioni online, sebbene dotate dei suddetti codici identificativi. In tal modo, si è ritenuto di potere adeguatamente limitare a validi testi di approfondimento la verifica della sussistenza del*

¹⁶⁰ Nota 2 febbraio 2011- Organismi di mediazione ed enti di formazione: nota illustrativa per la compilazione dei modelli di domanda.

requisiti in esame, dovendo essere caratterizzati, in primo luogo, dalla naturale destinazione a tutti i possibili esperti e non ad un limitato contesto; dall'altro, dalla destinazione al commercio del contributo realizzato: la finalità è, evidentemente, quella di evitare la presentazione di pubblicazioni di comodo non aventi alcuna referenza qualificata di provenienza”.

In definitiva i librai potranno dire che continuano a non pubblicare addirittura per volontà del Ministero.

Così non ci saranno in Italia nuovi libri sull'argomento, né formatori di peso, né progresso scientifico e conseguentemente nemmeno nuovi mediatori qualificati.

Il Ministero ci dice però che si può pubblicare su riviste dotate di ISSN ed ottenere così con soli tre articoli i requisiti da formatore.

Il che comporta un passaggio immediato dalle stelle alle stalle sotto vari profili (non si poteva scegliere una soluzione intermedia?).

Se per qualche caso la rivista di un ente pubblico fosse collegata ad un organismo di formazione si potrebbero ad esempio creare con facilità degli "automi della formazione".

Ragazzi appena usciti dall'Università che per 1.500 euro girano instancabili l'Italia per insegnare a mala pena (ma proprio a mala pena) il testo del decreto legislativo; ragazzi speranzosi che incolpevolmente non hanno e non apportano alcuna cultura nella materia della mediazione.

Bastano due scarabocchi su qualche rivista interna, tre mediazioni ed il gioco è fatto! E via in aula!

Mi congratulo con loro che hanno finalmente trovato un lavoro; mi congratulo pure con gli Enti di formazione che a fronte di un introito di quasi cento sessanta mila euro mensili ne

corrispondono l'uno per cento ai forzati della comunicazione: i caporali del Sud in confronto sono operatori di misericordia.

Sono certo che verranno pure gli imprenditori cinesi ad imparare da gli organismi italiani come si fa davvero impresa.

Gli enti di formazione appena descritti sono i nemici della conciliazione che più temo.

Quelli che operano all'interno della mediazione finalizzata alla conciliazione e stanno già cominciando a rottamare ciò che ancora non esiste.

Riusciremo a superare anche questa tempesta?

Autore

Carlo Alberto Calcagno svolge la professione di avvocato in Genova e Savona. Riveste anche la carica di conciliatore Unioncamere, mediatore civile e commerciale ed infine quella di mediatore sociale. Vanta inoltre una lunga esperienza come

docente, scrittore ed operatore nel campo del diritto del lavoro e della risoluzione alternativa dei conflitti.

Recapiti

Via Amba Alagi 16126 Genova

Tel 010/0014772 Fax 0108607451

carloalberto_calcagno@fastwebnet.it